

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

Recurso de apelación/certeza en la prueba/existencia de la falta y la responsabilidad del servidor procesado.

CERTEZA EN LA PRUEBA PARA SANCIONAR

De acuerdo con el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 *"No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado"*.

CERTEZA EN LA PRUEBA/ PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Respecto de la certeza exigida en la prueba para sancionar la Procuraduría General de la Nación ha señalado que *"El orden jurídico procesal presupone, entonces, la indubitable y plena demostración de la inequívoca conducta disciplinable, como requisito ineludible del debido proceso, previa la exigencia de responsabilidad. Consecuentemente no se podrá resolver en materia disciplinaria si no obran en el proceso legalmente producidas las pruebas que conduzcan a la certeza sobre la existencia de la falta (aspecto material u objetivo) y la responsabilidad del disciplinado (aspecto subjetivo). (Art. 142 ibidem) (...) Por certeza debe entenderse ese valor epistemológico o conocimiento particular que excluye toda duda razonable, al que se llega mediante el proceso racional de evaluación del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia"*¹

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2014-336
Número y fecha del fallo:	Fallo No. 5 del 9 de mayo de 2018
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo confirma totalmente el fallo sancionatorio proferido el 6 de febrero de 2018

FALLO No. 5 DEL 9 DE MAYO DE 2018

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2014-336.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

La Dirección General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el procesado, XXXXX, en contra Del fallo sancionatorio proferido el seis (6) de febrero del año en curso, por el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias, por medio del cual lo sancionó como autor, disciplinariamente responsable, de la falta disciplinaria contenida en el

¹ Procuraduría Regional de Santander 07 de marzo de 2016. Rad. IUS D 2012-82-550960IUS 2012-351173

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior dentro del proceso administrativo disciplinario No.1704-01-2014-336.

II. COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente recurso de apelación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3º del Decreto 0985 del 14 de mayo de 2012, y conforme al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior por tratarse de una decisión de un fallo de primera instancia proferido por el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias.

III. HECHOS

Los hechos originarios de la presente actuación disciplinaria fueron puestos de presente ante la Subdirección de Gestión de control Disciplinario de la DIAN, por el servidor público XXXXX, en su condición de Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga (Santander), mediante oficio de fecha 15 de diciembre de 2014.

Relató el informante haber recibido una llamada telefónica de una persona que omitió informar su nombre, quien manifestó que el funcionario XXXXX, perteneciente al Área de Recaudo y Cobranzas de esa seccional, solicitó la suma de cuatrocientos mil pesos moneda corriente (\$ 400.000) con el fin de agilizar la expedición de un certificado requerido por la Notaría Séptima del Circuito de Bucaramanga (Santander), dentro del trámite de sucesión del causante XXXXX.

IV. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Las diligencias fueron inicialmente conocidas por la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN y luego remitidas por competencia a esta Agencia, mediante correo electrónico del 26 de diciembre de 2014.
2. Posteriormente, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de esta Entidad ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del funcionario XXXXX, mediante decisión calendada el 5 de enero de 2015. Esta decisión le fue notificada personalmente el 17 de enero de 2015 (folios 51 a 57).
- 3.- Vencido el término de la indagación preliminar, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias profirió el auto de fecha 3 de julio de 2015, a través del cual se ordenó la apertura de investigación disciplinaria, decisión que fue notificada personalmente al investigado el 13 de julio de 2015 (folios 300 a 308).
- 4.- El 11 de enero de 2017, el operador jurídico de instancia ordenó el cierre de la etapa de investigación, decisión que notificó personalmente el 20 de enero de 2017. (folios 420 a 428). El mérito de la investigación fue evaluado mediante auto proferido el 30 de mayo de 2017, en el cual se llamó a responder disciplinariamente al procesado por considerarlo presunto responsable de incurrir en la falta gravísima descrita en el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, relacionada con la realización objetiva de la conducta penal contenida en el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano). El Pliego de cargos fue notificado mediante edicto desfijado el 30 de junio de 2017. (folios 432 a 456).

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

5.- Con auto del 24 de julio de 2017, la primera instancia dispuso rehacer la notificación del pliego de cargos enviando las comunicaciones pertinentes por correo electrónico. (folio 477).

6.- Mediante decisión proferida el 8 de septiembre de 2017, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias resolvió negativamente una petición de nulidad invocada por el disciplinado y decretó pruebas de oficio. Los sujetos procesales fueron notificados mediante correo electrónico. (folios 490 a 493).

7.- El 9 de enero de 2018, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias ordenó correr traslado a los sujetos procesales para presentar sus alegatos de conclusión. (folios 502 y 503).

8.- El 6 de febrero de 2018, el operador jurídico de primer grado declaró la responsabilidad disciplinaria del procesado por la falta objeto de acusación. Como consecuencia, le impuso como sanción la destitución de su cargo e inhabilidad general por el término de diez (10) años. Los sujetos procesales fueron notificados mediante comunicaciones enviadas a sus correos electrónicos durante los días 7 y 8 de febrero de 2018. (folios 510 a 530).

9.- El procesado envió correo electrónico interponiendo recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el cual fue recibido en esta entidad el 19 de febrero de 2018 (folios 532 a 534). El recurso fue concedido el 28 de febrero del año en curso en el efecto suspensivo y las diligencias recibidas en esta Dirección General, el 2 de marzo de 2018.

V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN APELADA

Los seis primeros títulos del fallo apelado contienen un recuento de la identidad del investigado; de los hechos; del cargo formulado y los argumentos defensivos expuestos por el procesado en su versión libre, en sus descargos y alegaciones de conclusión. También contiene las pruebas documentales y testimoniales sustento de la decisión.

Comenzando el título 6.3. de la valoración probatoria, el a quo consideró necesario reiterar, de manera previa y tal como lo aseveró al momento de la formulación de cargos, que se encuentra excluida la supuesta confesión realizada por el procesado sin el cumplimiento de sus requisitos. Adicionalmente y dada la importancia del testimonio rendido por XXXXX, realizó un estudio jurisprudencial relacionado con el valor probatorio del testigo único.

A partir del numeral 6.3.3. titulado como “del caso concreto”, el fallador de instancia valoró el testimonio del ciudadano XXXXX, apreciándolo como creíble y coherente frente al restante material probatorio. Determinó la primera instancia que, con esa declaración, se corroboró la presencia del procesado en el día y lugar de ocurrencia de los hechos, así como su relación funcional con la expedición de paz y salvos o certificaciones destinadas a ser aportadas en los trámites de sucesorales. Destacó el a quo la claridad con la que el testigo reconoció al servidor investigado como la persona que lo atendió el 9 de diciembre de 2014, día en que radicó el oficio proveniente de la Notaría 7ª del Círculo de Bucaramanga (Santander), así como la solicitud indebida objeto de reproche.

Para el operador jurídico de primer grado el relato del ciudadano XXXXX, es veráz y creíble al confirmarse, entre otros aspectos, la carga laboral que para ese momento manejaba el procesado, situación que, según el relato del afectado, fue argumentada por el disciplinado al momento de realizar la ilegal exigencia dineraria.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

En los argumentos posteriores, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias ratificó los elementos estructurantes de la falta disciplinaria, tales como la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, necesarios para declarar la responsabilidad del procesado como autor de la falta gravísima, cometida a título de dolo, consagrada en el artículo 48, numeral primero, de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 404 de la Ley 599 de 2000.

El título 7 del fallo apelado contiene una reiteración de la posición asumida por el a quo, con relación a la exclusión de la supuesta confesión ilegal del procesado, así como la valoración del testimonio ofrecido por el ciudadano afectado, apreciado y corroborado en conjunto con las restantes pruebas testimoniales y documentales de la actuación. Se condensan en este acápite los planteamientos de respuesta a los argumentos de defensa del servidor procesado.

El juicio de dosificación de la sanción a imponer aparece desarrollado a partir del título 9 de las consideraciones. Para este efecto, se partió de la sanción de destitución e inhabilidad general establecida por el legislador para las faltas gravísimas dolosas, como la que fue objeto de reproche en el presente juicio. Para determinar el término de duración de la inhabilidad se tuvieron en cuenta como criterios en favor del procesado los siguientes: no pertenecer al nivel directivo de la entidad, no afectación de derechos fundamentales y no haber causado perjuicios de carácter patrimonial para el Estado.

Con estas motivaciones, concluyó el fallador de primer grado, que en contra del servidor procesado debía imponérsele una sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez años.

VI. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

El recurso de apelación fue interpuesto de manera oportunamente por el procesado, quien solicitó que se revoque el fallo apelado y que, en lugar de lo ordenado, sea absuelto de la falta disciplinaria establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Para fundamentar su petición razonó de la siguiente manera:

A partir del título "**MOTIVOS DE INCONFORMIDAD**", el apelante considera sensata y razonable la decisión asumida por el a quo de excluir como medio de prueba su presunta confesión, considerando que:

"(...) el operador insiste en utilizar, revivir este medio de prueba, extractando apartes de los testimonios aportados por las personas que presenciaron esta diligencia ilegal, (refiriéndose a la reunión liderada por el servidor XXXXX), que ni siquiera debió mencionarse en la investigación pues contaminan el proceso "doctrina del fruto del árbol envenenado". (folio 532)

Sobre este mismo aspecto en particular agregó:

"(...) Es que no solo la llamada confesión fue la parte ilegal de la diligencia, sino toda la actividad que rodeó ese concierto para que terminara en confesión, por tanto, debe desaparecer del mundo procesal aquí debatido." (folio 532).

En un segundo grupo de ideas titulado como "FRENTE AL VALOR PROBATORIO OTORGADO AL TESTIGO ÚNICO", aseveró el sujeto procesal recurrente lo siguiente:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

"(...)Es pertinente señalar, que si bien es cierto que ante la existencia de una única fuente probatoria para analizar y valorar, su análisis razonable y coherente que se debe hacer es a través de las reglas de la sana crítica, por lo que resulta procedente conceder valor al testigo único como una fuente viable y legítima de convicción, atendiendo el contexto ponderado de sus planteamientos y las características y particularidades inherentes a la forma en que dicho testigo tuvo contacto con la situación o hecho objeto de la investigación, pero igualmente ahondando en la misma fuente a fin de encontrar situaciones o hechos que pudiesen llevar al operador disciplinario a la conclusión de que dicha prueba es incorruptible o no y así no quebrantar de tajo principios básicos que se deben tener en cuenta, como el señalado en el artículo 129 de la Ley 734 de 2002 que señala:".

"(...)Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba, El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad, Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio." (folio 532).

Los tres párrafos subsiguientes corresponden a una transcripción realizada por el sujeto procesal apelante de algunos apartes de la jurisprudencia citada por el fallador de instancia, al referirse al tema del testigo único. Haciendo referencia a esas líneas jurisprudenciales, continuó su exposición expresando que el operador jurídico de instancia no fue imparcial al valorar el testimonio del señor XXXXX. En concepto del recurrente, el análisis de la instancia sobre este medio de prueba hizo referencia a cuestiones obvias como su ubicación y cargas laborales, que en ningún momento demuestran con certeza la realización de la conducta imputada.

Agregó el recurrente que el fallador a quo bien pudo haber decretado los testimonios de sus tres compañeros de trabajo, ubicados a una distancia no superior a un metro y medio, quienes hubieron podido declarar sobre la información suministrada al quejoso el día de los hechos.

Haciendo referencia al desapasionamiento, como característica en el dicho del quejoso, el impugnante manifestó, de manera crítica, que dicho testigo ya había ordenado su cometido al obtener la certificación en un tiempo límite, saltando el orden cronológico de llegada y atención de otras solicitudes. Agregó que, en el testigo, existió un interés particular, pues si no obtenía dicha certificación con anualidad de 2014, tendría obligación fiscal en el 2015, implicando probablemente más costo fiscal y menos masa herencial a repartir.

Continuando con la crítica del testimonio del quejoso, adujo el recurrente que la instancia no analizó por qué dicho testigo se dirigió directamente al área de cobranzas y no a la sección de correspondencia, como correspondía. Igualmente, señaló como mentirosa la afirmación del testigo de ubicar al director seccional, a través de una supuesta amiga, la señora XXXXX, quien nunca existió. Por último, reiteró sus críticas al mismo testimonio, afirmando que no se debió permitir que el declarante lo identificara ilegalmente, cuando asistió a dicha diligencia, en ejercicio de su derecho de defensa. Con estos planteamientos, afirmó el impugnante que no debió la instancia conceder la credibilidad y solidez necesarias al dicho del quejoso.

Finalmente, para el apelante no fueron tenidos en cuenta, su carga laboral y su desempeño siempre sobresaliente como funcionario de la DIAN.

En un título final "FRENTE A LA ILICITUD SUSTANCIAL "expresó el recurrente lo siguiente:

"(...) Considero con todo respeto, que ante la inexistencia de tipicidad en la conducta, pues ratifico que nunca pedí nada a cambio por el ejercicio de mis deberes, por sustracción de materia no existe ilicitud sustancial." (folio 534).

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

VII. FUNDAMENTO DE LA DECISION

Este despacho se pronunciará frente al recurso de apelación presentado y sustentado por el procesado XXXXX, contra el fallo sancionatorio proferido el seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias, dentro del expediente disciplinario 1704-01-2014-336. Para ese fin, esta Dirección General seguirá el siguiente orden:

- A. Validez de la actuación.
- B. Existencia o no fundamento para proferir fallo sancionatorio.
 - 1. Presupuestos para proferir fallo sancionatorio.
 - 2. Aspectos probatorios del fallo.
 - 2.1. De la exclusión de la presunta confesión.
 - 2.2. Del valor probatorio otorgado al testigo único.

A. Sobre la validez de la actuación.

Este Despacho advierte que la actuación de primera instancia surtida por el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias fue promovida con respeto de las garantías fundamentales de trascendencia constitucional, las reglas de competencia y la estructura procesal contemplada en la Ley 734 de 2002.

Cada una de las etapas procesales (desde la indagación preliminar hasta el fallo) respetó el debido proceso y fue llevada a cabo por el funcionario competente. Para lo anterior, tenemos que el Decreto 4173 de 2011 otorgó competencia a la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias para conocer las faltas gravísimas taxativamente señaladas cometidas, entre otros, por funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Respecto a la falta gravísima contenida en el artículo 48 numeral 35 de la Ley 734 de 2002, está dentro de las contempladas en el factor objetivo de competencia.

La estructura procesal fue respetada porque se cumplieron cada una de las etapas, esto es, la indagación preliminar, la investigación disciplinaria, el cierre de la investigación, la etapa de descargos y los respectivos traslados que dispone la ley. Además, las decisiones fueron notificadas en debida forma y, aunque en derecho disciplinario la defensa técnica es facultativa, la disciplinada estuvo asistida de un abogado de confianza y contó con las oportunidades procesales necesarias para hacer valer sus derechos.

Consecuentemente, no concurren motivos para invalidar lo actuado y hay lugar a una decisión de fondo por parte de la Dirección General de la Agencia ITRC.

B. Sobre la existencia o no de fundamento para proferir fallo sancionatorio

1) Presupuestos para proferir fallo condenatorio

Según el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. Con relación a la certeza exigida en la prueba para sancionar ha dicho la Procuraduría General de la Nación:

"El orden jurídico procesal presupone, entonces, la indubitable y plena demostración de la inequívoca conducta disciplinable, como requisito ineludible del debido proceso, previa la exigencia de

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

responsabilidad. Consecuentemente no se podrá resolver en materia disciplinaria si no obran en el proceso legalmente producidas las pruebas que conduzcan a la certeza sobre la existencia de la falta (**aspecto material u objetivo**) y la responsabilidad del disciplinado (**aspecto subjetivo**). (Art. 142 ibidem) (...) Por certeza debe entenderse ese valor epistemológico o conocimiento particular que excluye toda duda razonable, al que se llega mediante el proceso racional de evaluación del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia”²

Por otro lado, de conformidad con el artículo 48 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, comete falta disciplinaria quien realiza objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. Lo anterior es un tipo en blanco que nos remite a la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y, para el caso particular, el artículo 404 que establece el delito de concusión, el cual comete un servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite.

Como consecuencia de lo anterior, debe determinarse si en contra del señor XXXXX, funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), concurre o no fundamento probatorio suficiente para declararlo responsable de la falta disciplinaria referida en párrafo anterior. De ser así, se confirmará el fallo recurrido; en caso contrario, se revocará.

2) Aspectos probatorios del fallo

2.1. De la exclusión de la presunta confesión

Es importante resaltar que la solicitud de exclusión probatoria de prueba ilícita fue atendida por el a quo de manera acertada y desde el momento mismo en que se llamó a responder disciplinariamente al acusado. Por tal razón, el funcionario de instancia fue enfático en afirmar que el requisito probatorio para la formulación de cargos estaba fundado en las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso disciplinario, excluyendo la confesión como prueba para llegar a la certeza de la existencia de los hechos y la responsabilidad del procesado.

En el acápite correspondiente a la respuesta de los argumentos defensivos, el operador jurídico de primer grado resaltó que compartía la manifestación del investigado, en el sentido de señalar que la reunión sostenida al interior de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga (Santander) no fue el instrumento idóneo para obtener la confesión como medio de prueba.

Sin embargo, pese a lo anterior, el informe de servidor público que diera origen de esta actuación no podía ser excluido como prueba documental, en razón a que el mismo constituía la materialización de un deber legal que le asistía al Director Seccional, XXXXX, en el sentido de poner en conocimiento de la autoridad competente, un hecho con relevancia disciplinaria que llegó a su conocimiento, en ejercicio de sus funciones.

Adicionalmente, es claro que la confesión no fue tomada en cuenta ya que el a quo hizo referencia a la inexistencia de los requisitos esenciales de este medio de prueba, con lo cual ratificó que en este proceso no fue tomada como tal la supuesta o presunta confesión del procesado. Estos mismos argumentos, al momento mismo de la valoración probatoria realizada por el fallador de instancia, fueron reiterados como consideración preliminar al enfatizar que la presunta confesión, en el

² Procuraduría Regional de Santander 07 de marzo de 2016. Rad. IUS D 2012-82-550960 IUS 2012-351173

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

marco probatorio del caso sub examine, fue excluida por inobservancia de los requisitos propios para soportar su validez.

A pesar de la reiteración constante que a lo largo del proceso realizó la instancia, dejando en claro la exclusión o inexistencia del aludido medio probatorio, la posición del apelante resulta simplemente reiterativa al expresar:

" (...) De otra parte y como quiera que el operador disciplinario inicia de una manera sensata y razonable reconociendo la ilicitud de una diligencia adelantada por el Director Seccional de la Dian de Bucaramanga y que en su informe o queja la denominó "confesión" determinando su exclusión como medio de prueba, no puedo decir lo mismo de la conclusión tomada frente a los hechos y todos los aspectos que rodearon el constreñimiento y la amenaza (al mejor estilo de la época de la inquisición, donde el sujeto objeto de reproche confesará (sic) o no de todas formas era condenado a la hoguera, diligencia que el quejoso "XXXXX" y el operador disciplinario llaman "Reunión concertada") pues no obstante lo anterior, el operador insiste en utilizar, revivir este medio de prueba, extractando apartes de los testimonios aportados por las personas que presenciaron esta diligencia ilegal, que ni si quiera debió mencionarse en la investigación pues contaminan el proceso "doctrina del fruto del árbol envenenado".". (cursiva fuera de texto).

Frente al anterior argumento de impugnación, en el que simplemente se muestra un interés de repetir la posición defensiva expuesta a lo largo del proceso, sin ofrecer ningún argumento adicional o nuevo, del que pudiera evidenciarse un ánimo de controversia, frente a la tesis del fallador a quo, la posición de este despacho de segundo grado no puede ser otra que rechazar el razonamiento del apelante, impartándole total aprobación a la valoración probatoria de la instancia, en lo que atañe a la exclusión de la supuesta confesión, obtenida, como allí se dijo, sin observancia de los requisitos legales.

2.2. Del valor probatorio otorgado al testigo único

En lo que a este aspecto se refiere, el despacho considera que igualmente a lo señalado en el punto anterior, deben rechazarse los argumentos del apelante, en los cuales simplemente descalificó la imparcialidad del fallador a quo, haciendo transcripción inicial de algunos párrafos correspondientes a la jurisprudencia citada por la instancia, con relación al tema jurídico mencionado.

Ahora bien, pese a la generalidad e indeterminación que igualmente se aprecia en este tópico de la sustentación del recurso, el despacho considera prudente hacer algunas precisiones al recurrente, con las cuales se avala en su totalidad la valoración probatoria de la instancia, encontrándose así cumplido el requisito probatorio previsto en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, indispensable para proferir, tal como acertadamente se hizo, una decisión de carácter sancionatorio.

Sin lugar a dudas, la aplicación de los postulados de la valoración probatoria del testigo único se hizo necesaria en el presente caso ante la existencia de un testimonio directo y principal, como lo fue la declaración del quejoso XXXXX, quien resultó ser la víctima o sujeto pasivo de los hechos de la conducta típica de concusión, siendo además la persona que alertó a la Dirección Seccional de Aduanas de Bucaramanga (Santander), sobre el comportamiento antiético que estaba realizando uno de sus funcionarios al interior de la División de Recaudo y Cobranzas.

En el análisis o valoración totalmente acertados del fallador de instancia, encontraron en el dicho del declarante XXXXX, situaciones de coincidencia frente a la apreciación de las restantes pruebas

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

testimoniales y documentales que permitieron otorgarle total credibilidad, demostrando con certeza que la solicitud dineraria indebida existió y que fue realizada por el funcionario procesado.

Contrario a lo manifestado por el recurrente, estas coincidencias entre el dicho juramentado del ciudadano XXXXX y los restantes medios probatorios, no resultan ser situaciones tan obvias, pues corresponden más bien a un adecuado ejercicio de valoración probatoria en el que se aprecia la contundencia y veracidad de sus afirmaciones frente a los hechos que, independientemente fueron demostrados por el operador jurídico, en desarrollo del presente juicio. Veamos por qué:

El testigo directo de los hechos narró y ratificó nuevamente su dicho que:

"(...) me acerqué a solicitar un paz y salvo necesario para el trámite de la sucesión de mi padre que se estaba llevando acabo (sic) en la notaria 7 (sic), hable con la (el) funcionaria a ver si el paz y salvo podría salir antes que terminara (sic) el año 2014, eso fue en diciembre el tres o cuatro de diciembre no se la fecha exacta, el señor fue muy cordial me atendió muy bien pero me dijo que habían (sic) como unas ochenta solicitudes antes de la mía que por eso iba a ser difícil que saliera en el 2014, sin embargo me dijo que tranquilo que no me preocupara porque estábamos para ayudarnos, palabras más palabras menos lo que me dijo fue que el me colaboraba pero que le ayudara con una suma de dinero con cuatrocientos mil pesos que eso no tenía problema que cuanto antes sacaba la certificación, como debía hacer la declaración parcial del 2014 (sic) hasta diciembre que cuando la trajera, trajera ese dinero (...)" (folio 61)

Sobre las circunstancias posteriores al hecho, el testigo contó que no accedió al pago del dinero solicitado por el funcionario público y que, por el contrario, trato de comunicarse con el director seccional para informar la situación, así:

"Tengo una amiga que es amiga personal del director y era difícil comunicarme o ir directamente (a) hablar con el director le dije me paso esto me parece que el director debe saberlo y quería decírselo personalmente sin embargo no pude obtener el teléfono no el acceso al Director estaba de viaje no recuerdo exactamente ella le comentó que se trataba de algo así que era para esa gestión, horas después me llamo (sic) el asesor jurídico no recuerdo el nombre me llamó la doctora Hortensia no recuerdo el apellido (...)" (folio 62)

Establecida la situación fáctica narrada por el testigo que fue sujeto pasivo de la conducta, es menester estudiar la coherencia interna y externa (la presencia de elementos periféricos) para determinar su credibilidad.

Sobre la coherencia interna, tenemos por parte del testigo concordancia en los detalles dentro de su relato e, incluso, en su ampliación posterior, donde narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que le fue solicitada la suma aludida; la narración se constituye como un mensaje coherente y no existen contradicciones. Sobre la coherencia externa, debemos valorar las pruebas de los hechos que rodearon los hechos relatados por el testigo, así:

El testigo narró que a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga (Santander) por una certificación para el trámite sucesoral de su padre, siendo atendido por un funcionario que le solicitó la suma de \$400.000 para tramitar con prontitud el documento y quien adujo que tenía una carga laboral de aproximadamente 80 solicitudes.

Lo anterior guarda coherencia con las demás pruebas que confirman la ubicación laboral del servidor público XXXXX, pues fue él -y no otro-, quien para el día y hora en que ocurrieron los hechos se encontraba asignado en el lugar donde finalmente hizo presencia el declarante XXXXX.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

Además, se demostró la función del servidor público de atender ese tipo de requerimientos, como eran los relacionados con la expedición de certificaciones para trámites notariales. Como pruebas de estas afirmaciones encontramos, entre otras, la certificación laboral expedida por la Subdirectora de Gestión Personal (folios 58 y 59), la comunicación de funciones, el oficio suscrito por la servidora XXXXX del Grupo de Gestión de Cobranzas de la División de Gestión de Cobranzas de la Seccional Bucaramanga (folio 112) y del testimonio de la jefe del grupo, doctora XXXXX, quien señaló que la función principal del hoy procesado era la expedición de este tipo de certificaciones (folios 71 a 74).

Significa lo anterior que la referencia concreta del testigo, corroborada testimonial y documentalmente, permitió la individualización e identificación certera del servidor implicado.

Adicionalmente, la referencia de la carga laboral mencionada por el declarante fue igualmente corroborada por la instancia, lo que permitió deducir la credibilidad del relato, cuando aseveró que el servidor encartado adujo como presunta razón para su exigencia ilegal de dinero, tener que resolver con prelación 80 requerimientos similares, siendo esta la supuesta razón que lo motivó a su actuar ilegal.

Ahora bien, el apelante sostiene que las únicas circunstancias que valoró el operador de primera instancia sobre las circunstancias y las pruebas de la coherencia externa del testigo son su carga de trabajo y sus funciones. Lo anterior no corresponde con la realidad pues existen pruebas adicionales que confirman la coherencia externa del testigo único, a saber:

El testigo narró las circunstancias posteriores a la solicitud indebida de dinero, refiriendo que acudió a una amiga -que identificó como XXXXX-, para obtener el contacto del director seccional, pero al no obtener el número y no poderse comunicar con él, le contó lo sucedido a su amiga, quien se comunicó telefónicamente con el director. Lo anterior guarda correspondencia con lo dicho por el doctor XXXXX, director de esa seccional de la DIAN, quien se ratificó en que recibió una llamada telefónica de una mujer en la que le manifestaron que el funcionario XXXXX había solicitado una suma de dinero para agilizar la expedición de una certificación solicitada por la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga, donde se tramitó la sucesión del causante XXXXX.

De otra parte, el testigo adujo que horas después recibió una llamada por parte de un funcionario de la DIAN que le ofreció disculpas por la situación. Este punto también está corroborado externamente por pruebas testimoniales, pues el doctor XXXXX, Gestor adscrito al despacho del director general de esa seccional, señaló que el director seccional tenía el número telefónico del usuario ya que "llamó (...) para quejarse y le dejó los datos y el Dr. XXXXX se los suministró a la Dra. XXXXX" (folios 237). Agregó el testigo que la doctora XXXXX le proporcionó el número del celular del hoy quejoso XXXXX, a quien llamó telefónicamente. Cobra aquí especial importancia la declaración del señor XXXXX, como el abogado de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga (Santander), quien, al sostener la comunicación telefónica con el contribuyente afectado, se enteró directamente del motivo de la inconformidad o reclamo, ante lo cual este servidor ofreció excusas por el comportamiento ilegal desplegado por uno de los servidores de esa dependencia.

Si bien el apelante aduce que nunca se pudo corroborar la existencia de XXXXX -persona que se comunicó telefónicamente con el director seccional-, la respuesta del testigo atiende los postulados de las reglas de la experiencia pues señaló que no puede conseguir el número telefónico del director seccional, pero al considerar que debía conocer la situación le comentó a una amiga que lo conocía. Si lo anterior lo sometemos a un análisis crítico, es claro que existe un

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

factor externo que confirma esta situación, pues el mismo director seccional testificó que recibió una llamada telefónica de una mujer que le informó sobre la solicitud ilícita de dinero.

Por otra parte, el apelante argumentó en su recurso que “tampoco se analizó porque se dirigió (refiriéndose al usuario) al área de dicha certificación, si los documentos se dejan en la sección donde se recepciona la correspondencia y los demás detalles los conoce la notaría que adelanta el proceso voluntario de la herencia, no se indagó el por qué (sic) tuvo que ir a la División de Cobranzas”. Sobre este punto, es claro que el testigo narró que acudió a esa división, aduciendo que: “(...) en la portería me ubican con él porque traía un oficio de la notaría y me dicen que en cobranzas o cobro coactivo” (folio 62). Adicionalmente, que el señor XXXXX decidiera radicar personalmente el oficio proveniente de la Notaría Séptima, sin esperar el trámite oficioso del requerimiento, no varía la calificación de la conducta ni la responsabilidad, pues fue esa la razón por la cual tuvo contacto con el procesado.

Con relación al hecho de haberse efectuado, por parte del testigo XXXXX, el reconocimiento del procesado, como el funcionario que realizó la ilegal solicitud de dinero, este despacho no encuentra ninguna situación de ilegalidad o irregularidad, como lo pretende el procesado, como requisito de procedibilidad de la investigación, se realizó en la presente actuación, con base en las pruebas documentales y testimoniales practicadas preliminarmente, siendo totalmente innecesario e improcedente acudir a otros procedimientos. De esta forma se avala en su totalidad la posición tomada al respecto por el fallador de instancia.

Ahora bien, contrario a lo manifestado por el sujeto procesal recurrente, considera este despacho que no existen las presuntas afirmaciones mentirosas en el dicho del señor XXXXX, pues su relato, respecto a la forma en que decidió acceder ante la Dirección Seccional de Aduanas de Bucaramanga (Santander), para poner en conocimiento lo sucedido, no difiere para nada frente a las aseveraciones de los distintos servidores que fueron vinculados a la actuación, en calidad de testigos, frente a la forma en que tuvieron conocimiento del hecho y al manejo inmediato que se le dio a la situación, bajo precisos y posiblemente desafortunados lineamientos, dados por el entonces director seccional.

Como resultado de lo anterior y evidenciando que la narración del testigo guarda relación con otras pruebas allegadas a la actuación, esta segunda instancia comparte la valoración probatoria efectuada por el Subdirector de Investigaciones Disciplinaria, concluyendo que de la declaración juramentada del testigo XXXXX y en las restantes pruebas practicadas, se demostró con certeza la existencia de la falta y la responsabilidad del servidor procesado.

Basten las anteriores consideraciones para concluir que este despacho rechazará las razones de impugnación del apelante, confirmando en su totalidad el fallo sancionatorio impugnado, tal como se declarará en la parte resolutive de la presente decisión.

En tal virtud, la Directora General de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

PRIMERO. RECHAZAR, las razones de impugnación presentadas por el sujeto procesal apelante, XXXXX, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación en segunda instancia dentro del expediente 1704-01-2014-336.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior determinación, **CONFIRMAR TOTALMENTE** el fallo sancionatorio proferido el 6 de febrero de 2018, por el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Unidad Administrativa Especial Agencia ITRC, a través del cual se sancionó con **DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE diez (10) AÑOS**, al servidor público XXXXX, por encontrarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria, cometida en las circunstancias de modo, tiempo y lugar allí mismo referidas.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, se ordena **REGISTRAR** la sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente, se ordena **REMITIR** copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y párrafo del artículo 172 del C. D. U.

SÈPTIMO. Ejecutoriada materialmente esta decisión, libradas las comunicaciones de ley, **DEVUÉLVASE** el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARCELA MONCADA BARRERA
Directora General (E)

Proyectó: Demetrio Augusto Parra Jiménez

Aprobó: Marcela Moncada Barrera. – Directora General (e).